



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000206040

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000175-39.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDAÇÃO ARMANDO ÁLVARES PENTEADO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores SOUZA NERY (Presidente) e OSVALDO DE OLIVEIRA.

São Paulo, 26 de março de 2018.

Souza Meirelles

Relator
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível nº 0000175-39.2017.8.26.0053
Apelante: *Fundação Armando Alvares Penteado*
Apelada: *Municipalidade de São Paulo*
Comarca: *São Paulo*
Vara: *2ª Vara da Fazenda Pública*
Juiz prolator: *Dr. Marcelo Sergio*
TJSP (voto nº 10974)

Ocupação e uso do solo – Mandado de segurança -
Municipalidade de São Paulo - Expedição de
Declaração de Potencial Construtivo Transferível de
imóvel – Descabimento – Classificação diversa da
sustentada - Imóvel com tombamento em curso
(Tombamento Provisório), situado em bairros
clausulados (Pacaembu e Perdizes) – Inteligência do
art. 124, §2º da Lei Municipal nº 16.050/14 –
Impossibilidade de transferência de potencial
construtivo originário de bairros tombados –
inexistência de ilegalidade – precedente desta E. Corte
- Denegação da segurança confirmada – recurso
desprovido

Apelação cível manejada por **Fundação Armando
Alvares Penteado** nos autos de mandado de segurança impetrado contra
ato do **Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Paulo**
e do Diretor do Departamento de Uso e Ocupação do Solo do
Município de São Paulo, os quais tramitaram na 2ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo, cuja ordem foi denegada.

Vindica a apelante a desconstituição da r. sentença, a fim de que concedida a segurança para reconhecer a ilegalidade das decisões administrativas combatidas, de não emitir a declaração de potencial construtivo transferível para o bem imóvel de propriedade da impetrante.

Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls. 124/130).

A **E. Procuradoria Geral de Justiça** se manifestou pelo desprovimento do apelo (fls. 137/139).

Tal, em abreviado, o relatório.

Mandado de segurança impetrado por Fundação Armando Alvares Penteado objetivando seja emitida em favor da impetrante, proprietária do imóvel SQL n. 011.086.0001-8 (localizado à Rua Alagoas, nº 903, Higienópolis, São Paulo/SP), a Declaração de Potencial Construtivo Transferível nos termos dos **arts. 122 a 133 da Lei nº 16.050/2014 – Plano Diretor Estratégico da Cidade de São Paulo**, em razão da **Resolução SC 32.102/94**.

Após regular processamento, sobreveio sentença de denegação da ordem, em face da qual a impetrante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Assim, a impetrante manejou o recurso de apelação que ora se analisa.

Em que pese ao inconformismo, o recurso não comporta provimento.

Mister se faz notar que o *mandamus* foi impetrado desacompanhado de documentação satisfatória, desatendendo ao dever de juntar prova pré-constituída do direito tendo em vista que pela via do mandado de segurança é reconhecido o direito certo e líquido.

De todo modo, passa-se à apreciação do mérito diante da análise dos elementos juntados e das transcrições dos atos administrativos na petição inicial.

Em princípio, cabe esclarecer que o controle dos atos administrativos deve ser feito apenas dentro dos estreitos liames da legalidade, não se cogitando de invasão à seara discricionária da autoridade coatora.

Conforme bem pontuado pelo perínclito **Des. Ricardo Anafe**, “*é defeso ao Poder Judiciário, analisar o mérito do ato administrativo, isto é, sob o aspecto de sua justiça (Cf. RTJ 56/333), restringindo-se a temática à legalidade estrita, o que sobressai em sede de writ of mandamus,*

cujo procedimento sumaríssimo da mandamental, obsta dilação probatória" (TJSP, Ap. Cív. nº 0023831-35.2011.8.26.0053, 13ª Câ. Dir. Púb, j. 16.5.2012).

A toda evidência, não se verifica qualquer ilegalidade no ato impugnado.

Dessume-se dos autos que o bem imóvel está em processo de tombamento (fls. 36/37), o que significa dizer que submetido a restrições, restando vedada a intervenção nos termos de modificação ou destruição que venham a descaracterizá-lo, contudo resta preservada normal utilização do bem pelo proprietário, não lhe retirando o direito de posse.

Como já dito, pretende a impetrante a emissão da Declaração de Potencial Construtivo Transferível, entretanto necessário observar as condições do imóvel e a legislação especial aplicável.

Nesse contexto, o indeferimento do pedido administrativo da impetrante se deu nos seguintes termos: *"O imóvel identificado no cadastro municipal sob SQL 011.086.0001-8 encontra-se em processo de tombamento pelo PA CONDEPHAAT SC 32.102/1994 e não está enquadrado como ZEPEC-BIR, portanto não atende ao inciso I, do artigo 124 da Lei nº 16.050/2014, conforme informação nº 003/16/SMDU/DEUSO, sendo considerada improcedente a solicitação e INDEFERIDO o requerimento"* (fls. 3).

Inconformada, a Fundação recorreu, contudo, foi mantida decisão administrativa: *“Em vista do contido nos presentes autos, em especial das manifestações da Divisão de Monitoramento de Uso do Solo (fl. 43 v.) e da Assessoria Jurídica desta Secretaria (fls. 46/49), com fundamento nos arts. 61 e 124 Lei Municipal nº 16.050/14, art. 36 da Lei nº 14.141/2006 e art. 72 do Decreto nº 51.714/2010, CONHEÇO o recurso interposto em face da decisão do Diretor do departamento de Uso do Solo, manifestada pela Despacho nº 014/2016/SMDU. DEUSO, publicado no DOC de 09 de janeiro p.p. e no mérito, NEGOU PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada por seus próprios fundamentos”*.

Por reputar a decisão administrativa carente de motivação legal, recorreu ao Prefeito de São Paulo, que negou provimento: *“” Em vista dos elementos presentes aos autos, em especial das manifestações do Departamento de Uso do Solo – DEUSO – de fls. 43 v. e 69 e da Assessoria Jurídica deste Gabinete – de fls. 70/754, cujos fundamentos adoto como razão de decidir, CONHEÇO das razões interpostas pela Fundação Armando Alvares Penteado, inscrita no CNPJ sob o nº 61.451.431/0001-69 e representada nestes autos por seu advogado CYRO ROBERTO CARDOSO DE AS WERNECK DE ALMEIDA, OAB Nº 280.718, porque tempestivo, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, quanto ao mérito, por ausência de amparo legal. II – Dou assim por encerrada a instância administrativa, com fundamento no artigo 36, caput e §2º da Lei Municipal nº 14.141/2006” (fls. 5).*

Consabido, o art. 35, §2º, do Estatuto da Cidade dispõe que “A lei municipal referida no caput estabelecerá as condições relativas à aplicação do direito de construir”.

Constata-se do **art. 124** da **Lei Municipal nº 16.050/14** (Plano Diretor):

Art. 124 - O potencial construtivo passível de transferência, nos casos em que não há a doação do imóvel cedente, deverá observar as seguintes disposições:

I - os imóveis enquadrados como ZEPEC-BIR e ZEPEC-APC poderão transferir o potencial construtivo básico definido em razão de sua localização;

II - os imóveis enquadrados como ZEPAM, localizados na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana e cadastrados na Planta Genérica de Valores da Prefeitura de São Paulo poderão transferir seu potencial construtivo básico.

§ 1º A transferência de potencial construtivo prevista no inciso II do "caput":

I - dependerá de autorização do Conselho Gestor do FUNDURB e de parecer favorável da Secretaria do Verde e Meio Ambiente - SVMA;

II - ficará condicionada à celebração de Termo de Compromisso Ambiental - TCA, que deverá ser averbado na matrícula do imóvel, no qual o proprietário do imóvel cedente assume as obrigações de preservação das características da área, e são definidas as sanções cabíveis previstas pela legislação ambiental no caso de descumprimento das obrigações assumidas.

§ 2º Não poderão ser realizadas transferências de potencial construtivo originário de bairros tombados em Área de Urbanização Especial (AUE) e das Áreas de Proteção Paisagística (APPa).

§ 3º Quando o potencial construtivo passível de transferência ultrapassar 50.000m² (cinquenta mil metros quadrados), a transferência do que exceder este

limite se dará de forma gradativa em dez parcelas anuais, incluindo as declarações já emitidas anteriormente à publicação desta lei.

Infere-se, portanto, a possibilidade de emissão da Declaração de Potencial Construtivo a imóvel enquadrado como ZEPEC-BIR, ZEPEC-APC ou ZEPAM. Ocorre que, em virtude do incontroverso tombamento do Bairro em que se encontra o imóvel em questão, conforme Resolução nº 42/92 do CONPRESP, o imóvel da impetrante foi enquadrado como ZEPEC-QUE (Área de Urbanização Especial), categoria em que é vedada a transferência de potencial construtivo (§2º supratranscrito).

Em que pese sustente a apelante que o imóvel se encontra na categoria ZEPEC-BIR, por encontrar-se em processo de tombamento, ressaltando no mais o contemplado no **art. 10, parágrafo único**, do **Decreto-Lei 25/1937**, não restou flagrante tal presunção até mesmo porque os bens em processo de tombamento provisório não possuem necessariamente o mesmo regime de bens já tombados.

Nesse sentido, o **art. 166¹** da **Lei 16.402/16**, que disciplina o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de São Paulo, de acordo com a **Lei nº 16.050/2014** (Plano Diretor Estratégico - PDE), enuncia que os imóveis serão desenquadrados como ZEPEC “se no período de 2 (dois) anos após a publicação desta lei não tiverem sido tombados pelos órgãos de preservação competentes”.

¹ Art. 166. Os imóveis ou territórios demarcados como ZEPEC, com fundamento no inciso I do art. 64 da Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014 – PDE, indicados para tombamento no Mapa 2 desta lei e aqueles com processo de tombamento aberto serão automaticamente desenquadrados como ZEPEC se no período de 2 (dois) anos após a publicação desta lei não tiverem sido tombados pelos órgãos de preservação competentes.

Destarte, não se entende possível a alteração da categoria nos moldes em que sustentado pela recorrente, sendo legítima a decisão administrativa, fundamentada na legislação municipal pertinente.

A corroborar o entendimento, julgado desta **E. Corte** acerca de caso crivado pela analogia:

MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante que almeja a expedição de Declaração de Potencial Construtivo Transferível de imóvel, com alteração da classificação da categoria de zoneamento – Descabimento - Imóvel com tombamento em curso (Tombamento Provisório), situado em bairro tombado (Pacaembu e Perdizes) (SC 08/91/CONDEPHAAT) – Tombamento Provisório que se equipara ao Definitivo (art. 10, par. Único, do Decreto-Lei nº 25/37) – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do C. STJ – Lei Municipal nº 16.050/14, que dispõe expressamente ser impossível a transferência de potencial construtivo originário de bairros tombados (art. 124, par. 2º) – Denegação da segurança mantida – Recurso da impetrante não provido. (TJSP; Apelação 0000177-09.2017.8.26.0053; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/10/2017; Data de Registro: 20/10/2017)

Sendo assim, de rigor a manutenção do julgado de origem.

Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Postas tais premissas, por meu voto, **nego provimento** ao recurso.

Souza Meirelles
Desembargador Relator